

1501072-96.2022.8.26.0544
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Érica Midori Sanada
Comarca: Vinhedo
Foro: Foro de Vinhedo
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 17/08/2022
... (RJTJSP 75/343).

Nesse sentido: RT 538/380. "Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO- Pretensão de absolvição por falta de provas ou desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/06 Impossibilidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Vinhedo
Foro de Vinhedo
2ª Vara
Estrada da Boiada, 530, Vinhedo - SP - cep 13289-086

1501072-96.2022.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1501072-96.2022.8.26.0544
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CLAYTON NUNES CUNHA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Midori Sanada

Vistos.

CLAYTON NUNES CUNHA, já devidamente qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, incisos III da Lei nº 11.343/06, porque no dia 20 de abril de 2022, por volta das 16h10min, na Av. Antônio Conselheiro, na altura do nº 75, Jd. Nova Canudos, nesta cidade e Comarca de Vinhedo, teria mantido em depósito 29 porções de tetrahydrocannabinol, vulgarmente conhecido como maconha, com peso bruto aproximado de 126,9g (cento e vinte e seis gramas e nove decigramas), para fins de tráfico e entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Constatou ainda na denúncia, que os fatos se deram em um campo de futebol, ao lado de uma creche municipal.

A denúncia foi recebida em 23 de maio de 2022 (pág. 76/77).

O réu foi citado (pág. 201/202) e apresentou defesa (pág. 157/166).

Na resposta à acusação, argumentou a Defesa que o réu é inocente, sendo que ele foi forjado pelos policiais, que ainda o agrediram. Em sede de preliminar, aduziu que a denúncia é inepta, bem como que há falta de justa causa penal e insuficiência probatória. No mérito, pugnou por sua absolvição, com base na ausência de autoria. Em caso de condenação, pugnou pela aplicação de pena restritiva de direito ou ainda, suspensão condicional da pena. Ao final, arrolou as mesmas testemunhas de acusação.

Na audiência de instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas e, por fim, foi o réu interrogado.

Em debates orais finais, pugnou o(a) representante do Ministério Público pela procedência da ação, condenando-se o réu nos termos da denúncia. Em seguida a Defesa pugnou pela improcedência da ação, alegando fragilidade probatória.

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Da Materialidade:

A materialidade do delito ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (pág. 05), pelo boletim de ocorrência (pág. 18/20), pelo auto de exibição e apreensão (pág. 23/24), pelo laudo de constatação provisória (pág. 26/28), pelo exame químico toxicológico definitivo (pág. 63/65), com resultado positivo para THC – TETRAHIDROCANABINOL – MACONHA, bem como pelos depoimentos prestados na fase policial e em juízo.

Das Provas Colhidas em Juízo:

Na fase policial o réu CLAYTON NUNES CUNHA, assim relatou:

“Que é amigo de Marlon e, na ocasião dos fatos, tinha acabado de encontrá-lo no campo de futebol; que Marlon o chamou para fumar maconha; que Marlon tinha duas porções de maconha acondicionadas em ziplog, e o indiciado outras duas porções de maconha, também acondicionadas em ziplog. Que logo que começaram a fumar, surgiu a polícia militar. Que, durante a abordagem, levou uma cabeçada no rosto, que lhe feriu a boca. Informa que tinha no bolso R\$ 90,00 e R\$150,00 dentro da carteira. Questionado sobre as demais 27 porções de maconha acondicionadas também em ziplog, nega a propriedade droga. Informa que não carrega qualquer bolsa ou mochila, mas que Marlon tinha consigo uma mochila preta na qual, durante a revista, viu que havia uma chuteira, bola e fones de ouvido”. Em juízo declarou que tinha saído da cadeia e procurou serviço de jardinagem. Recebeu 400 reais e gastou o dinheiro, sobrando 240 reais. Na volta para casa, encontrou o Marlon e fumou com ele. Foram abordados e levados para a delegacia. Não estava traficando. Não sabia que o local era ponto de tráfico de drogas. Conhecia o policial Joailton por abordagem anterior. Na abordagem, informou que só tinha o dinheiro recebido pelo trabalho, que não tinha droga. Levou uma cabeçada no rosto. Foi pressionado a informar onde estava a droga. Mostrou o machucado para escrivã na delegacia. O policial Ferreira disse que não era para o declarante informar da cabeçada na delegacia.

Por sua vez, o policial militar JOAILTON SILVA MARTINS, assim esclareceu na fase policial:

“Que estava com o parceiro SD PM Ferreira pela Rua Ana Lombardi Gasparini, quando foram abordados por uma senhora que informou que havia visto dois rapazes vendendo droga perto de uma creche, os quais eram vistos por lá. Que foram ao local informado e avistaram dois indivíduos em frente ao campo de futebol, ao lado da Creche Marques de Rabicó. Ao perceberem que iam ser abordados, Marlon dispensou duas porções de substância análoga a maconha no campo de futebol. Que procederam à

abordagem e, em revista, encontraram na carteira de Clayton a quantia de R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) em dinheiro; questionado, Clayton respondeu que saiu da cadeia há pouco tempo estava traficando, tendo ainda indicado uma bolsa, embaixo de uma árvore, onde havia 27 porções idênticas às dispensadas por Marlon. Marlon, por sua vez, respondeu que havia comprado as duas porções de droga de Clayton, pelo valor de R\$ 20,00. Diante dos fatos, deram voz de prisão para Clayton, o qual foi algemado por receio de fuga, e conduziram as partes para esta unidade policial". Declarou em Juízo que estava em patrulhamento quando foi abordado por uma senhora informando sobre a venda de drogas perto da creche. Ao se aproximarem, um indivíduo jogou uma substância no campo. O Marlon informou que jogou 2 porções de maconha que comprou com o Clayton. O Clayton confessou o crime. Foi encontrado mais droga perto de uma árvore em uma bolsa preta pequena. Não houve violência na abordagem. O Clayton ficou nervoso quando foi informado que seria levado para a delegacia. Já havia abordado o Clayton antes desse fato.

Na sequência, o policial militar DOUGLAS ALVES FERREIRA, assim relatou na fase policial:

"Que estava em patrulhamento com o parceiro SD PM Joailton pela Rua Ana Lombardi Gasparini, quando foram abordados por uma mulher informando que havia visto dois rapazes vendendo drogas perto de uma creche, os quais frequentemente eram vistos por lá. Foram ao local informado e avistaram dois indivíduos em frente ao campo de futebol, ao lado da Creche Infantil Marques de Rabicó. Ao perceberem que iam ser abordados, Marlon dispensou duas porções de substância análoga a maconha no campo de futebol. Procederam à abordagem e, em revista, encontraram na carteira de Clayton a quantia de R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) em dinheiro; questionado, Clayton respondeu que saiu da cadeia há pouco tempo estava traficando, tendo ainda indicado um estojo de óculos preto, próximo de onde estavam, onde havia mais 27 porções idênticas às dispensadas por Marlon; Marlon, por sua vez, respondeu que havia comprado duas porções de maconha com Clayton, pelo valor de R\$ 20,00; Diante dos fatos, deram voz de prisão para Clayton, o qual foi algemado por receio de fuga, e conduziram as partes para esta unidade policial, onde a autoridade de plantão deu voz de prisão em flagrante delito". Em Juízo, declarou que estava em patrulhamento no dia dos fatos, sendo informado por uma senhora que havia um sujeito vendendo drogas. Ao se aproximarem, verificaram que um indivíduo lançou um objeto no campo de futebol. Fizeram a abordagem nos dois indivíduos e encontraram uma substância aparentando ser maconha no campo de futebol. Foi encontrado dinheiro com o Clayton. Foi encontrado um estojo com maconha embaixo de uma árvore. O Marlon informou que comprou a droga com o Clayton. Não houve agressão. Não conhecia os envolvidos.

Após, a testemunha MARLON ANTUNES DE SÁ, assim consignou na fase policial:

"Que é usuário de maconha há aproximadamente seis meses. Que estava em sua residência e foi no campo de futebol próximo à sua casa jogar bola. Que sabia que o rapaz que fica ali próximo vende maconha. Nunca havia comprado e nem tem contato com o mesmo, que solicitou duas porções e quando pegou a primeira os Policiais já abordaram ambos, trazendo todos para a Delegacia". Em Juízo, declarou que já estudou o Clayton. Era usuário de maconha. Estava no mesmo local do Clayton no momento do flagrante. Não sabe se o local é ponto de drogas. Não Foi algemado. Viu o policial agredindo o réu no momento da abordagem, dando uma cabeçada no rosto do Clayton. Pegou uma porção de droga com o Clayton. Prestou declaração falsa na delegacia, tendo em vista que não comprou a droga com o Clayton, somente usou a droga com ele. Deu a declaração falsa por medo de ser incluindo com um dos proprietários das drogas encontradas. No momento da abordagem, não viu os policiais encontrando mais droga.

Por fim, a escrivã de polícia FERNANDA ALBINO DE OLIVEIRA, assim consignou na fase policial:

"Presentes neste plantão os Policiais Militares informando que estavam pela Avenida Ana Lombardi Gasparini, quando uma transeunte informou que havia visto um rapaz vendendo drogas próximo a creche. Diante da informação, dirigiram-se ao local e avistaram dois indivíduos, do lado de fora de um campo de futebol, ao lado da creche. Ao serem abordados, Marlon jogou duas porções de substância análoga a maconha no campo de futebol, enquanto Clayton foi encontrado com R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) dentro da carteira, e indicou uma bolsa, embaixo de uma árvore, onde havia 27 porções idênticas às que estavam com Marlon. Indagado, Marlon informou que havia comprado as duas porções de Clayton, pelo valor de R\$ 20,00. Diante dos fatos, conduziram as partes para esta unidade policial, tendo sido Clayton algemado por receio de fuga, onde a Autoridade Policial ratificou a voz de prisão de Clayton pelo crime de tráfico de drogas, e a Marlon foi imputado o artigo 28 da Lei de Drogas, tendo sido ele colocado em liberdade, ciente que deverá comparecer em juízo quando notificado. Importante constar que durante a lavratura deste flagrante, no trânsito entre a sala de oitiva e a cela, o indiciado Clayton fugiu correndo desta unidade policial, sendo perseguido por policiais e novamente preso após alguns quarteirões, com a ajuda de outro policial que passava com seu veículo particular. Importante constar também que Clayton, apenas em seu interrogatório, informou sobre uma lesão na boca, supostamente provocada pelos Policiais Militares durante sua prisão, e seria levado a Unidade de Pronto Atendimento; no entanto, devido a fuga, será atendido diretamente pelo IML, conduzido pela equipe de investigadores desta unidade". Em Juízo, ratificou o que havia dito na fase do inquérito e acrescentou que o Marlon não foi coagido a apresentar a versão declarada por ele. Ficou sabendo que o Clayton tentou fugir. O Clayton confessou o crime.

Do Valor e do Conjunto da Prova:

Dos Depoimentos dos Policiais Militares:

É importante salientar que a lei penal não furta valor ao testemunho dos agentes de segurança, na medida em que não os dispensa do compromisso de dizer a verdade e nem os poupa do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar ou adulterar os fatos.

Aliás, nem teria sentido conferir-lhes a lei determinada tarefa para depois, quando viessem prestar contas de sua atuação, negar-lhes valor aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não dizem a verdade.

Anoto que pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas não são suficientes para afastar tal prova.

Consigno que o próprio Colendo Supremo Tribunal Federal deixou assentado:

"O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar, tal como ocorre com as demais testemunhas, que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC nº 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Face as provas colhidas nos autos, a quantidade de droga apreendida e a forma como estava dividida, bem como, os depoimentos seguros prestados pelos agentes, levam à certeza de que o réu traficava drogas na ocasião, impondo-se, pois, a sua condenação.

Nessa linha: "Apelação – Justiça Pública – Tráfico de Drogas – Condenação – Necessidade – Materialidade e autoria comprovadas – Apreensão de 20 pedras de crack – Depoimentos seguros e harmônicos dos policiais responsáveis pelo flagrante –

Suficientes elementos para embasar a condenação - Pena - Dosimetria - Pena-base fixada no mínimo legal - Incidência da circunstância agravante da reincidência - Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas por ausência de preenchimento dos requisitos - Imposição de Regime Fechado. Recurso de Apelação provido para condenar o réu André da Silva Ferreira à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a 583 dias multa em seu mínimo unitário, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343, de 2006, fixado o regime fechado para início do cumprimento da pena, expedindo-se mandado de prisão em desfavor do réu, após o trânsito em julgado." (Apelação nº 0006970-48.2012.8.26.0114, da Comarca de Campinas. 4ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo. Relator: César Augusto Andrade de Castro. Julgado em 29/04/2015).

De se alinhar que a prova dos autos não consiste apenas no depoimento dos policiais militares, face todo o acervo produzido nos autos, seja em Juízo, seja na fase policial.

Do Pedido de Desclassificação do Delito:

Diante o conjunto probatório dos autos, demonstrando-se claramente a traficância, não se autoriza a pretendida desclassificação da conduta como simples consumo pessoal (artigo 28, da Lei nº 11.343/06).

Anoto que nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, e face as demais provas colhidas nos autos, competia ao requerido comprovar que seria apenas usuário de entorpecentes, o que não foi feito.

Neste sentido: "Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343).

Nesse sentido: RT 538/380. "Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO- Pretensão de absolvição por falta de provas ou desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/06 Impossibilidade - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas nos autos - Versão do réu restou incomprovada - Palavras dos policiais civis - Não haveria como se questionar tais depoimentos, eis que se revestem de fé-pública e foram corroborados pelas demais provas Traficância - Condenação era de rigor - Penas e regime inicial fechado corretamente aplicados- Impossibilidade de substituição das penas corpóreas por restritivas de direitos - Recurso defensivo desprovido. (Apelação nº 3009705-74.2013.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo. 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Relator: Edison Brandão. Julgado em 12/05/2015).

EMENTA: Apelação criminal Tráfico ilícito de entorpecente - Sentença condenatória - Apelo do réu objetivando a absolvição ou a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria demonstradas - Depoimentos de policiais valiosos na elucidação dos fatos. Razoável quantidade de cocaína apreendida, além de grande quantia em dinheiro trocado. Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório- Penas e regime prisional escorreitamente fixados - Gravidade concreta da conduta do apelante que revela a sua elevada danosidade social, a reclamar, portanto, a manutenção do regime eleito, servindo, de resto, como obstáculo à substituição da pena corporal por restritivas de direitos - Recurso improvido. (APELAÇÃO Nº 0002426-75.2011.8.26.0397. Comarca de Nuporanga. 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Relator: Moreira da Silva. Julgado em 12/02/2015).

Do Crime de Tráfico:

O crime de tráfico de entorpecente é de mera conduta, bastando, para a sua consumação, a prática de qualquer um dos núcleos verbais do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, independentemente da concretização ou não da entrega ao destinatário, pelo que a simples conduta do réu, consistente em "manter em depósito" a substância entorpecente, já é suficiente para caracterização do delito:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663).

No caso em tela restou devidamente comprovado nos autos, que os policiais militares estavam em patrulhamento de rotina, quando foram informados por uma transeunte, que no campo de futebol, ao lado da Creche Infantil Marques de Rábicó, estavam dois indivíduos vendendo entorpecentes, os quais sempre eram vistos no local.

Chegando ao local dos fatos, avistaram dois indivíduos, sendo que MARLON dispensou duas porções de maconha, quando avistou a aproximação da viatura. Na abordagem, encontraram com o réu CLAYTON, a quantia de R\$ 240,00 em dinheiro. Questionado, informalmente CLAYTON confessou que havia saído da cadeia há pouco tempo e que estava na mercancia dos entorpecentes. Ele ainda indicou aos policiais, o local onde estava escondido um estojo de óculos com 27 porções de maconha, com embalagem idêntica aos entorpecentes dispensados por MARLON, conforme auto de exibição e apreensão (pág. 23/24). Questionado, MARLON informou que era usuário de drogas e que havia comprado as duas porções de CLAYTON e pago a quantia de R\$ 20,00.

Ouvido na fase policial, a testemunha MARLON informou ser usuário de maconha. No dia dos fatos, ele foi jogar bola no campo de futebol e sabia que o rapaz que lá se encontrava, vendia entorpecentes. Pediu então as duas porções, quando então chegaram os policiais militares e os encaminharam até à Delegacia de Polícia. Em Juízo modificou sua versão alegando que o réu não teria vendido a droga.

Ouvido na fase policial e em Juízo, o réu negou os fatos, dizendo que estava com MARLON e ambos são usuários de maconha. Os outros entorpecentes não lhe pertencem. Que de fato estava com dinheiro, proveniente de seu trabalho. Aduziu ainda, que MARLON é que estava com uma mochila.

Em que pese o quanto argumentado pelo réu, não há motivos para se duvidar das palavras dos policiais militares, já que estes não teriam qualquer motivo para incriminá-lo. Anoto que pequenas divergências nos depoimentos não afastam o valor da prova.

Enfim, diante o conjunto probatório, cabia ao réu provar versão contrária, fato do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Em sede de defesa, aduziu o réu que foi forjado e agredido pelos policiais. Entretanto, conforme constou no Boletim de Ocorrência (pág. 18/20), o réu fugiu de dentro da Delegacia de Polícia, sendo perseguido pelos policiais, que com a ajuda de outro policial que estava na rua, conseguiram detê-lo.

Portanto, apesar dos argumentos do réu há dúvida em que momento houve a lesão e se ela realmente aconteceu por conta da abordagem policial. E, não obstante isso, é certo que tal fato será apurado pelo órgão competente e, em nada modifica os fatos ora apurados.

Frise-se que a versão trazida nesta data de MARLON foi, no mínimo, confusa, na

tentativa vã de eximir o requerido de sua culpabilidade. MARLON confirmou que não foi coagido a falar na fase policial e que, realmente, falou para a escrivã que tinha comprado as drogas do requerido. Hoje, argumentou, de forma, repito, confusa, que falou isso por medo, diante a quantidade de drogas que foram apreendidas e que, como não é traficante, resolveu levar tal versão à autoridade policial.

Enfim, as drogas foram apreendidas, as testemunhas foram claras quanto as assertivas de MARLON, soando, repito, totalmente incongruente, destoante de verossimilhança a alegação que tenha querido acusar falsamente o réu na oportunidade em que foi ouvido na fase inquisitorial, para se livrar de eventual responsabilidade penal.

Com relação a mochila, pochete ou outro local em que foram encontradas as drogas, também não implicam na modificação dos fatos que estão sendo analisados por ocasião desta ação penal.

Acrescento que o artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006 traz dezoito núcleos para a caracterização do tipo penal, e qualquer deles é mais do que o suficiente para a caracterização do delito.

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Diante do exposto, a condenação do réu é medida que se impõe, nos termos do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006.

Do Artigo 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006:

Constou ainda na denúncia, que o réu teria cometido o delito de tráfico de entorpecentes, no campo de futebol, que fica ao lado de uma creche municipal.

Conforme os depoimentos dos policiais militares, das testemunhas e do réu, verifica-se que os fatos se deram ao lado do campo de futebol, ao lado da Creche Infantil Marques de Rabcó.

O artigo 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006, assim disciplina:

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos. (grifo nosso).

Restou demonstrado nos autos, que de fato o delito era praticado ao lado do campo de futebol e da Creche Infantil Marques de Rabcó, e tal fato, causa desequilíbrio social e desarmonia, razão pela qual a pena deve ser aumentada nos termos do artigo 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Absolvição por insuficiência de

provas Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos. Validade dos depoimentos dos agentes públicos Quantidade de entorpecentes e circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação à mercancia Majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06 que é de caráter objetivo, bastando que o delito seja praticado nas proximidades dos estabelecimentos elencados no referido dispositivo legal, como "in casu". Condenação bem lançada Pena criteriosamente aplicada Doutra maioria que entende que a figura privilegiada não retira o caráter hediondo do delito, sendo incabíveis a fixação de regime diverso do fechado e a substituição da pena privativa de liberdade Recurso defensivo desprovido, por maioria". (Apelação 0017626-70.2016.8.26.0196 - 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relator Camilo Léllis, DJe 19/06/2018).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. REGIME FECHADO. PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. A remissão feita pelo Magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o Juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Precedentes do STF. 2. Restou comprovado que o réu praticou o crime de narcotráfico próximo a local de cunho educativo, um estabelecimento de ensino, de sorte que a causa especial de aumento de pena, prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, deve ser reconhecida. Por sinal, é da prova oral judicial que o réu foi encontrado próximo a uma escola, com razoável quantidade de drogas, lugar que possui várias crianças e adolescentes, ou seja, vulneráveis à ação do narcotraficante. Precedentes do STF e do STJ. Inteligência da doutrina. 3. Regime inicial de cumprimento de pena para os crimes de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto. 4. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a quantidade do entorpecente apreendido demonstra que a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos não seria suficiente para a reprovação e a prevenção do crime em comento. 5. Provimento do recurso do Ministério Público." (Processo: APL 00071532720138260197 SP 0007153-27.2013.8.26.0197, Relator(a): Airton Vieira, Julgamento: 30/04/2015, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Publicação: 15/05/2015).

Passo a Dosar a Pena:

Sopesados os elementos norteadores do artigo 42, da Lei 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal, constato que o réu possui duas condenações por tráfico de entorpecentes, sendo que uma delas será utilizada como MAUS ANTECEDENTES, conforme certidão de objeto e pé de pág. 92/96, tendo em vista que foi condenado por tráfico de entorpecentes, que tramitou perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, sob o número 1501023-60.2019.8.26.0544 e transitou em julgado para a defesa em 10/07/2019, razão pela qual majoro a pena em 1/6, resultando na pena de: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, observo a agravante da REINCIDÊNCIA, conforme certidão de objeto e pé (pág. 92/96), tendo em vista que o réu foi condenado por tráfico de entorpecentes, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, sob o número 1501173-41.2019.8.26.0544 e transitou em julgado para a defesa em 23/09/2019, o que por si só autoriza a majoração da pena em pelo menos

1/6, no entanto, verifico que o réu é REINCIDENTE ESPECÍFICO, fato que agrava ainda mais a situação, razão pela qual, majoro a pena em 1/3, resultando na pena de: 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

No caso em tela, em que o réu já foi punido por um crime, voltar a delinquir, já é bastante grave, fato que justifica a agravante de reincidência. Porém, tornar a cometer a mesma infração que já cometera anteriormente mostra maior recalitrância, autorizando a aplicação de maior fração de aumento pela reincidência.

Neste sentido FRANCESCO CARNELUTTI que ao comentar a reincidência afirma que "atribui a lei particular importância quando se comete o novo delito depois da condenação pelo delito anterior; em tal caso o novo delito demonstra insensibilidade do réu à condenação e, eventualmente, também o castigo". Continua CARNELUTTI, comentando as disposições do Código Penal Italiano, que "a reincidência se agrava: a) se o novo delito é da mesma índole que o delito anterior: art. 99, n. 1, Cód. Penal; art. 101, Cód. Penal; a chamada reincidência específica".

Consigne-se que, segundo JOSÉ FREDERICO MARQUES, "na reincidência específica, estabelece-se a ligação entre dois ou mais crimes praticados pelo agente, não só quando violado, em todos eles, o mesmo dispositivo legal, mas também quando outros fatores de homogeneização possam ser encontrados mostrando que 'os crimes são da mesma natureza'".

É a orientação do Supremo Tribunal Federal de que o aumento pela reincidência específica seja maior que aquele determinado pela reincidência genérica.

"PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. DELITO DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, NO CASO, ESPECÍFICA. MAJORAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - O habeas corpus, ressalvadas hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo. II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima. III - A reincidência específica é agravante que sempre determina a exacerbação da pena, inclusive em maior grau do que a recidiva genérica, por evidenciar que o réu persiste na senda do crime. IV - Individualização da pena que, no caso, não desbordou dos lindes da razoabilidade e proporcionalidade. V - Ordem denegada". (HC 101918/MS - Mato Grosso do Sul, Ministro Relator: Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento: 11/05/2010).

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pelo maior aumento em razão da reincidência específica.

"A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, e acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. É 43 Ob.cit. p. 91. 44 Tratado de Direito Penal 1ª ed. Campinas: Millenium 2000 v. III p. 126. 45 STF HC nº 101918/MS rel. Min. Ricardo Lewandowski j. 11/05/2010. permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o julgado é claro em reconhecer a reincidência específica do paciente, fato que justifica o incremento da pena em 1/3 (um terço)".

Nesse sentido:

MATERIALIDADE auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a

presença do elemento ativo comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA depoimento policial que indica a apreensão de droga validade depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado inoportunidade no caso em tela. TRÁFICO destinação a terceiros indícios tais como a apreensão das drogas em posse dos réus; a tentativa de empreender fuga em conhecido ponto de venda de drogas; dão a necessária certeza de que a droga destinava-se ao comércio espúrio tipo congruente. PENA primeira fase pena-base majorada em 2/5 ante a natureza da droga apreendida manutenção segunda fase aplicada a agravante da reincidência específica, aumentando a pena em 1/3 - manutenção - não há atenuantes terceira fase não há causas de aumento inaplicável o redutor do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 ante a reincidência do réu. REGIME fechado réu reincidente específico regime fechado mostra-se como o único cabível para afastar o réu da senda criminosa negado provimento. (Apelação n.º 0011580-72.2017.8.26.0635 – 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Relator: Laudo Mens de Mello – Julgamento: 28/02/2019).

Logo, tratando-se de reincidência específica, mesmo única, impõe-se tratamento diferenciado. Como o entendimento pacífico que uma única reincidência exaspera a pena de 1/6, por ser específica impõe-se o aumento de 1/3.

Na terceira fase de aplicação da pena, como bem demonstrado nos autos, está presente a causa de aumento da pena prevista no artigo 40, inciso III da Lei n.º 11.343/2006, tendo em vista que o réu praticou o crime nas proximidades da “Creche Municipal Marques de Rabicó”, sendo assim, aumento a pena em 1/6, resultando em: 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 906 (novecentos e seis) dias-multa.

O réu é REINCIDENTE e portador de MAUS ANTECEDENTES, conforme certidão de objeto e pé (pág. 92/96), razão pela qual não vislumbro ser o caso de aplicação do benefício do privilégio, motivo pelo qual, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Ausentes outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena, esta pena torna-se definitiva.

Do Regime Inicial de Cumprimento da Pena:

O réu é REINCIDENTE e portador de MAUS ANTECEDENTES (pág. 92/96), além disso, o tráfico de entorpecentes é crime gravíssimo, pois a intenção do traficante é levar ao vício o maior número possível de vítimas. No mais, cuida-se de delito equiparado a hediondo, razão pela qual o réu deverá cumprir sua pena em regime inicialmente FECHADO, como expressamente previsto no artigo 2º, inciso II, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.º 11.464/07.

Não se faz presente a possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, porque tais benefícios são incompatíveis com a finalidade da Lei nº 8.072/90, que dá tratamento mais rigoroso aos chamados crimes hediondos e assemelhados e que prevê, dentre outras hipóteses, a fixação de regime inicial fechado para cumprimento da sanção imposta ao protagonista de delitos deste jaez.

Acerca da constitucionalidade da vedação à conversão da pena privativa de liberdade em sanção alternativa, nesse sentido, aliás, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, ponderando que embora tenha o Supremo Tribunal Federal afirmado ser inconstitucional a proibição de conversão de penas em crime de tráfico (HC 97.256, rel. Min. Ayres Brito), deve ser ressaltado que tal decisão foi adotada em sede difusa, por maioria de votos e sem efeito vinculante (cf. HC 168.459/MG, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 21/10/10).

Ressalto que o delito em questão, é de especial gravidade, consistindo em causa ou consequência da prática de outros crimes tão ou mais graves e intimamente ligados com a criminalidade violenta e com a desestruturação de inúmeras famílias.

Do Valor do Dia-Multa:

O valor do dia-multa deve ser calculado nos termos do artigo 43, da Lei n. 11.343/06, sendo fixado em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do pagamento, tendo em vista a ausência de elementos que pudesse majorar tal pena.

Não há que se falar na não aplicação da pena de multa, sob a alegação de que o réu é beneficiário da justiça gratuita, eis que a pena de multa está prevista no preceito secundário do tipo penal e fora estabelecida de acordo com a dosimetria da reprimenda corporal e ainda no mínimo legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício.

Nesse sentido:

Ementa: Tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante - Apreensão de quantidade razoável de crack - Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos - Responsabilidade do acusado comprovada - Condenação mantida; Tráfico de entorpecentes - Plena indicação de que o réu se dedica a atividades ilícitas e está ligado a organização criminoso - Redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - Inaplicabilidade - Multa - Pena prevista no preceito secundário do tipo de tráfico de entorpecentes e estabelecida de acordo com a dosimetria da reprimenda corporal e no mínimo legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício - Recurso improvido (Apelação Criminal n.º 0001590-39.2017.8.26.0544 - da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -Relator: Alexandre Almeida - Julgamento: 08/04/2021).

Do Dispositivo:

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que o Ministério Público move em face de CLAYTON NUNES CUNHA, já devidamente qualificado, para o fim de CONDENÁ-LO à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicialmente FECHADO, e ao pagamento de 906 (novecentos e seis) dias-multa, com valor mínimo legal, como incurso nas penas do artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III da Lei nº 11.343/06.

Da Prisão Preventiva:

O réu é REINCIDENTE e portador de MAUS ANTECEDENTES, conforme certidão de objeto e pé (pág. 92/96), e dada a necessidade de resguardo da ordem pública, assim como, para garantia de aplicação da lei penal, mantenho a prisão do requerido. Recomende-se.

Vale aqui consignar, que o réu já foi condenado em DUAS OPORTUNIDADES pelo delito de TRÁFICO DE ENTORPECENTES, e em outra oportunidade pelo delito de FURTO, e novamente, veio a praticar o mesmo delito, demonstrando seu desvio de caráter, personalidade criminoso e total ausência de ressocialização.

Frise-se que é imperiosa a decretação da custódia do réu, com o fim de garantir a aplicação da lei penal e preservar a coletividade contra pessoas potencialmente perigosas.

Quem enverada para prática desses tipos de criminalidade, indisfarçavelmente tem personalidade deturpada, causadora de risco à ordem pública.

Anoto, ainda, que a revogação da prisão cautelar seria contrária aos anseios da

sociedade, que clama por mais rigor na punição dos crimes que vêm causando imenso desassossego na sociedade, como é o de tráfico, crime de extrema gravidade.

A doutrina afirma que:

“As causas enumeradas no art. 312 são suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, visto que essa tem outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como a conveniência da instrução criminal e do assecuramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor da infração penal grave” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, editora RT, 9ª edição, p.635).

Dos Efeitos da Condenação:

Custas na forma da lei.

Autorizo a incineração da substância entorpecente apreendida. Se o caso, oficie-se.

Comprovada a traficância e o fato da importância encontrada com o réu ser proveniente/destinado ao tráfico, declaro a perda da mesma (pág. 23/24, 62 e 67) em favor da União nos termos do artigo 63, da Lei 11.343/2006.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Por fim, com relação a eventual instauração de inquérito policial em face da testemunha MARLON, entendo que tal deverá ser, se o caso, providenciado pelo parquet sem necessidade de intervenção do Juízo.

De qualquer forma, oficie-se a delegacia local, diante o B0 de pag. 18/20 se houve ou não a instauração de TC contra MARLON, devendo, por certo, a autoridade policial providenciar o necessário em caso de eventual omissão.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Vinhedo, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

Certifico que, na data inserida no sistema informatizado, foi publicada em cartório a r. Sentença. O escr.